

1000221-48.2016.8.26.0246
Classe: Ação Civil Pública
Assunto: Dano ao Erário
Magistrado: Luciano Correa Ortega
Comarca: Ilha Solteira
Foro: Foro de Ilha Solteira
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos" (Pazzagliani Filho, Marino; Elias Rosa, Márcio Fernando e Fazzio Júnior, Waldo. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996, p. 35).

O caráter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ilha Solteira
Foro de Ilha Solteira
1ª Vara
Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira - SP - cep 15385-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000221-48.2016.8.26.0246 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1000221-48.2016.8.26.0246
Classe - Assunto
Ação Civil Pública - Dano ao Erário
Requerente:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido:
Nilson Miranda Nantes

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MATEUS MOREIRA SIKETO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO propôs a presente Ação Civil Pública em face de NILSON MIRANDA NANTES alegando, em resumo, que o requerido, à época Diretor de Cultura do Município, contratou a empresa Uesley Janio Vieira Severo-ME, por meio do contrato n. 207/2010, no valor de R\$ 174.800,00, para intermediar a contratação dos artistas Paula Fernandes, Michel Teló, Banda Alma Serrana e a dupla Divino e Donizete. A contratação da referida empresa Uesley teria possibilitado que não se discriminasse no contrato administrativo o valor de cada show, mas tão somente o valor total, justificando os gastos nas contas do município e mascarando o superfaturamento das contratações. Ademais, a única empresa com carta de exclusividade para os referidos shows era a empresa de Uesley e com datas fornecidas pelos artistas muito próximas ao dia da abertura do procedimento licitatório e com a exclusividade tão somente para intermediar a contratação nas datas exatas agendadas para apresentação de cada artista na 28 Fapic. Pugna pela

procedência da ação, requerendo a declaração da nulidade do contrato n. 207/2010; condenação do réu nas sanções previstas nos incisos II do artigo 12 da lei 8.429/92.

A requerida apresentou defesa preliminar (fls. 382/401).

A inicial foi recebida (fls. 447/449).

Citada, o réu ofertou contestação (fls. 457/476).

O feito foi saneado (fls. 513/514).

Durante o curso da instrução foram produzidas as provas deferidas, como audiência de instrução e julgamento (fls. 536/542).

O Ministério Público ofertou alegações finais por escrito (fls. 543/572), assim como o requerido (fls. 771/781).

Decisão instando o Ministério Público, ante as alterações trazidas pela Lei n. 13.964/19 à Lei de Improbidade Administrativa, para a possibilidade de acordo de não persecução penal (fls. 788).

Manifestação do parquet (fls. 793)

Manifestação do réu pela ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 794/799).

Manifestação do MP (fls. 812/817).

Decisão afastando a prescrição intercorrente (fls. 832).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conforme escólio de José Afonso da Silva, a probidade administrativa consiste no dever de o "funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem" (Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, p. 669).

A improbidade administrativa pode ser definida como "a corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito, Democrático e Republicano) revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos" (Pazzagli Filho, Marino; Elias Rosa, Márcio Fernando e Fazzio Júnior, Waldo. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996, p. 35).

O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável aos agentes públicos que, por ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente: (a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); (b) causem prejuízo ao erário público (art. 10); (c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), compreendida nesse tópico a lesão à

moralidade administrativa.

A responsabilização dos agentes públicos por atos de improbidade deve se basear em provas concretas quanto aos atos que lhe são imputados, face às graves consequências que afetam a vida do eventual infrator. Para caracterização do ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, pois inadmissível a responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa.

No caso sub judice, a prova coligida demonstra de forma segura e convincente a ocorrência de ato de improbidade.

Dispõe o art. 25, III, da Lei 8.666/1993:

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. (sem grifo no original)”.

O caderno probatório revela que a empresa Uesley J. V. Severo -ME não era empresária exclusiva dos artistas contratados diretamente, sem licitação, para se apresentarem na FAPIC.

Basta uma simples leitura dos documentos abaixo listados para se concluir que a exclusividade pontual e diária foi obtida pela empresa Uesley após seu contato inicial com a Prefeitura de Ilha Solteira, como forma de dar uma aparência de legalidade ao procedimento de inexigibilidade de licitação n. 207/2010.

Com relação à artista Paula Fernandes, verifica-se a Carta de Exclusividade assinada pelo representante legal Walter Viúdes Junior da Talismã Music, em favor da empresa Uesley, em 07-10-2010, constando expressamente que o Walter era o representante legal da Paula Fernandes (fls. 185) e não a empresa Uesley. Nota-se, ainda, que a exclusividade é limitada ao dia do show da artista para 13 de outubro de 2010.

Quanto ao Michel Teló, verifica-se também que a Carta de Exclusividade assinada por Teló Produções Art. Ltda em favor da empresa Uesley, em 14-10-2010, constando expressamente quem é o representante exclusivo do artista. Aqui, da mesma forma, indicando que a exclusividade é apenas para a data do show, no dia 14 de outubro de 2010 (fls. 187).

Há, ainda, exclusividade em relação à Banda Alma Serrana, concedida pelo representante legal, João Ramão Monfort Villar, em favor da empresa Uesley, em 23-09-2010 (fls. 183). Novamente, a empresa Uesley não era representante ou empresário exclusivo da banda.

Por fim, a carta de exclusividade da dupla Divino e Donizete, representado por Acácia Promoções e Produções Artísticas Ltda, em favor da empresa Uesley, em 16-10-2010. Da mesma forma, indicando a exclusividade para o dia do show (fls. 184).

Analisando os referidos documentos, verifica-se que a empresa Uesley não era representante/empresário exclusivo das supracitadas bandas/dupla, tendo alcançado referida exclusividade apenas para atender ao contrato firmado com o Município, sem procedimento licitatório prévio, sendo a empresa intermediária aparente, em favor do réu.

Observa-se, também, que os valores desembolsados para a contratação de show foram de R\$ 85.750,00 e os valores realmente pagos à empresa Uesley de R\$ 174.800,00 (fls. 198/204).

Vejamos a prova oral.

A testemunha Guilherme Garcia Marques, funcionário público da prefeitura explicou como funcionam as contratações. Afirmou que, em regra, o Departamento de Cultura encaminha uma solicitação de contratação de determinado artista ao Departamento de Compra e, que, após os tramites formais, o contrato vai para assinatura e o diretor de cultura fiscaliza o cumprimento do contrato. O diretor de cultura também assina como testemunha para presenciar a assinatura do instrumento pelas contratantes.

A testemunha Luis Gustavo Collus de Paula, o qual sucedeu o réu na função de Diretor de Cultura, ratificou o depoimento da testemunha Guilherme quanto ao procedimento para contratação de artistas. Afirmou que, em regra, a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, é realizada com o empresário exclusivo do artista contratado. Aduziu que não conhece a empresa Uesley.

As testemunhas Alexandre Magliano Batista e Luiz Otavio de Oliveira Lima apenas informaram que os artistas que foram contratados são conhecidos nacionalmente.

A prova testemunhal pouco contribuiu para o deslinde do feito.

Ora, é mais do que óbvio que as festas promovidas atraem público da cidade e, também, de fora da cidade, movimentando a cidade em seus diversos setores. Mas também é óbvio que o mau emprego de verba pública, seja por mera irregularidade, ilegalidade ou decorrente de ato de improbidade prejudica escolas, unidades de saúde e os equipamentos públicos municipais, pois deixarão de receber o escasso dinheiro público, que muitas vezes não é bem empregado.

As "cartas de exclusividade" fornecidas pelos artistas em favor da empresa Uesley (fls. 183/187), para datas coincidentes com as dos shows, reforça o entendimento deste Juízo, de que na realidade foi utilizado estratagema pelo réu, para à época, burlar o dispositivo legal acima citado - art. 25, III, da Lei n. 8.666/93 - e possibilitar a contratação de artistas que já tinham outros empresários e que, de fato, não eram agenciados com exclusividade pela empresa Uesley.

Nesse ponto, aliás, o dolo surge com clareza solar. Ora, tanto o réu sabia que a inexigibilidade de licitação pressupunha contratação com empresário exclusivo, que logrou providenciar, antes da assinatura do contrato n. 207/2010 com este Município, as cartas de exclusividade, para cada uma das datas em que ocorreriam os shows. Se o réu ignorasse o dispositivo legal ou a exegese fosse distinta daquela extraída pela pessoa natural comum - homem médio - certamente não teria buscado cartas de exclusividade pontuais, sendo que a empresa Uesley simplesmente contrataria a dupla/banda para cada uma das datas diretamente com o empresário de cada uma delas, sem necessidade de obter cartas de exclusividade antes da sua efetiva contratação pelo Município.

As cartas de exclusividade, portanto, somente foram idealizadas, exigidas e recebidas porque o réu e a pessoa jurídica de direito privado precisavam dar uma aparência de legalidade ao procedimento de inexigibilidade de licitação n. 207/2010, de modo que, o mais incauto, poderia pensar que os pressupostos gizados no inciso III do art. 25 da Lei n. 8.666/93 foram atendidos, pois havia "exclusividade" em favor da empresa Uesley, dando aparência de que a empresa Uesley estava a frente das contratações.

Indo mais afundo, verificar-se-ia que a exclusividade foi fabricada, já que pontual e para uma data específica, não se tratando de empresário exclusivo. O dolo do réu,

assim, é evidente!

Os documentos de fls. 295/297 demonstram que a Banda Alma Serrana não celebrou contrato com a empresa Uesley (fls. 295), mas sim com o réu Nilson (fls. 297). Da mesma forma em relação ao artista Michel Teló. Os documentos de fls. 341/342 demonstram que o contrato foi firmado com o réu e não com a empresa Uesley.

Fica claro que o réu se utilizou da empresa Uesley como empresa intermediária de fachada, quando ele próprio firmava os contratos com os artistas. Corrobora com estes documentos, o testemunho de Luis Gustavo Collus de Paula, que substituiu o réu no cargo de diretor cultural e não conhece a empresa em questão.

Não há razão para se contratar artistas consagrados, que, sabidamente, já possuem empresários exclusivos próprios, por intermédio de terceiro, que certamente cobrou e recebeu uma comissão além daquela já paga ao verdadeiro empresário, onerando os cofres públicos e burlando a Lei de Licitações, conforme ficou demonstrado que as contratações dos shows foram de R\$ 85.750,00 e o valor pagos foi de R\$ 174.800,00 (fls. 198/204). Pior, ainda, quando o próprio funcionário público, em nome próprio assina os contratos dos shows contratados, como verdadeiro intermediário.

Em nenhum momento a Defesa do réu demonstrou a exclusividade apta a justificar a inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93. As alegações não passam de meras conjecturas na tentativa de validar procedimento ilegal.

O réu, assim, desviou da finalidade última da Administração Pública, qual seja, o atendimento do interesse público primário.

Desse modo, restou devidamente comprovado o dano ao erário público que o requerido provocou ao dolosamente lesar os cofres públicos por cobranças superiores ao valor dos shows contratados, incidindo na figura prevista no artigo 10 da LIA.

Concluo, portanto, pela nulidade do contrato n. 207/2010, e determino a devolução do valor superfaturado (R\$ 89.050,00). Isto, porque, acolher a devolução do valor integral ensejaria enriquecimento ilícito do Estado, posto que o serviço foi prestado.

“Aliás, (...) 3. Não cabe exigir a devolução dos valores recebidos pelos serviços efetivamente prestados, ainda que decorrente de contratação ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, circunstância que não afasta (ipso facto) as sanções típicas da suspensão dos direitos políticos e da proibição de contratar com o poder público. 4. A vedação de restituição não desqualifica a infração inserida no art. 10, VIII, da Lei 8.429/92 como dispensa indevida de licitação. Não fica afastada a possibilidade de que o ente público praticasse desembolsos menores, na eventualidade de uma proposta mais vantajosa, se tivesse havido o processo licitatório (Lei 8.429/92 - art. 10, VIII). (STJ, AgRg no AgRg no REsp. nº 1.288.585/RJ, rel. Min. Olindo Menezes, j. 16/02/2016)”

Atendendo ao princípio da proporcionalidade reputo como suficientes as demais sanções: a) a proibição de contratar com o poder público pelo prazo de cinco anos; b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; c) ressarcimento do valor superfaturado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido pelo Ministério Público e CONDENO o réu NILSON MIRANDA NANTES, às seguintes penas previstas no artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/92, tendo em vista a efetiva gravidade da conduta e a extensão do dano: a) declaração de nulidade do contrato administrativo n. 207/2010; b) ressarcimento das quantias recebidas indevidamente por superfaturamento (R\$ 89.050,00), cuja correção, nos termos da tabela prática do

TJSP, e juros de mora de 1% ao mês deverão observar a data da lesão ao cofre público; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos e d) suspensão dos direitos político pelo prazo de cinco anos.

Sucumbente a parte autora em parte mínima, arcará o requerido com o pagamento das custas e despesas processuais, não havendo fixação de honorários advocatícios por falta de amparo legal.

P.I.C.

Ilha Solteira, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA